



לפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
יעל ליבוביץ

תיק תביעה מס': 128/12

- בענין :**
1. פרוטר משה
 2. פרוטר חנה
 3. נציגות הבית המשותף ברח' וולנברג 24, חיפה

ע"י ב"כ עוה"ד מוטי כהן
מרח' פל-ים 5, חיפה 33095
טל : 077-4244373, פקס : 072-2123330

התובעים/
נתבעים שכנגד

נ ג ד

ליאורה ובנימין מילר

ע"י ב"כ עוה"ד יהודה מלאך
מח' העצמאות 84, חיפה 33034
טל': 04-8622144, פקס : 04-8622145

נתבעים/
תובעים שכנגד

פ ס ק - ד י נ

עסקינן בדרישת התובעים, נציגות הבית המשותף (להלן: "הנציגות") ובעלי דירה בבית (להלן: "פרוטר"), ליתן כנגד בעלים של דירה אחרת בבית (להלן: "מילר") צו עשה אשר יחייב אותם: לסלק את דוד המים החמים ואת המזגנים שהתקינו ברכוש המשותף. עניינה של התביעה שכנגד היא דרישת מילר ליתן כנגד פרוטר צו עשה אשר יחייב אותם: לסלק ידם מהמחסן המסומן בתשריט רישום הבית המשותף במספר 3 ומהווה חלק בלתי נפרד מדירת מילר; לסלק את הדלת שהתקינו בכניסה למסדרון המוביל למחסן 3 וכן לשלם למילר דמי שימוש ראויים בסך של ₪ 10,560 בעבור המחסן האמור.

במקור ביקשו התובעים גם להורות למילר להרוס מחסן שבנו בשטח המשותף; להחזיר את הניקוז שעובר בחצרם למצב המקורי, לרבות תיקון הנזקים שנגרמו לקיר ולגינת פרוטר; ולאפשר תיקון צינור הביוב המשותף העובר בקיר חדר האמבטיה של מילר, אך בהמשך צומצמה התביעה כפי שיפורט להלן.

העובדות הצריכות לעניין-

1. המדובר בבית משותף בן 4 דירות הנמצא ברח' ראול וולנברג 24, חיפה, המזוהה כחלקה 137 בגוש 10794 (להלן: "הבית/הבית המשותף").
2. הבית נרשם כבית משותף ביום 22.5.08. דירת מילר מזוהה ברישום כתת חלקה מס' 3. תיאור כל אחת מהדירות בבית כולל מחסן, וכן הוצמדו לדירות שטחים כמפורט במסמכי הרישום. המחסנים הודגמו בתשריט רישום הבית המשותף וסומנו במספור זהה למספור הדירות. אחד המחסנים סומן בספרה 3 ונרשם בתיאור הדירה כשייך לדירת מילר (להלן: "המחסן").
3. ביום 11.12.08 נרשם תיקון לצו רישום הבית המשותף. צו התיקון הקנה לבעליה של דירה תת חלקה מס' 3 (מילר) זכות שימוש בלעדית לדורות בשטח שמתחת לגרם המדרגות בקומת דירתם.

טענות התביעה-

4. לכל בעלי הדירות בבית הותקן דוד המים בתוך דירתם ורק מילר התקינה את דוד המים המשמש אותם בשטח המשותף המוביל למחסנים של פרוטר ורימוני. הדוד מטפף ויוצר כתמי חלודה על הריצוף. כן קיימת סכנה שבמקרה של נזילה חמורה הדוד עלול לה ציף את מחסני הדיר ות. לפיכך מבוקש לחייב את מילר להעתיק את הדוד אל תוך דירתם.
5. בעוד שכל בעלי הדירות בבית בחרו להתקין מזגן מיני מרכזי במיקום שתוכנן לכך ע"י הקבלן התקינה מילר על קירות הבית המשותף מזגנים נפרדים וצנרת ארוכה באופן המכער את קירות הבית וגורם למטרד של רעש.
6. מילר ריצפו את גינתם כאשר תוך כדי כך חסמו את הניקוז המקורי שנבנה. חלף תוכנית הניקוז המקורית פערו מילר בקיר המשותף בין גינתם לגינת פרוטר חור אשר דרכו הם מזרימים מים, כל זאת ללא אישור בעלי הדירות בבית ובאופן הפוגע במראה הבית.
7. בחדר האמבטיה של מילר עובר צינור ביוב משותף בו קיים ליקוי אשר בעטיו נוזלים מים אל תוך מחסן פרוטר. מילר אינם מאפשרים גישה ותיקון מתוך דירתם.

טענות ההגנה-

8. אין לקבל את התביעה היות ו הנציגות נוהגת איפה ואיפה בבית. הנציגות לא הגישה תביעות דומות כנגד בעלי דירות אחרים בבית שנטלו לידיהם ללא רשות שטחים משותפים.

9. במסגרת רישום הבית המשותף ותיקון צו הרישום הוקנו ל מילר השטחים נושא ההליך. המפקח על רישום מקרקעין אינו הערכאה הנכונה לתקיפת רישום הבית המשותף או התיקון שנרשם. ככל שקיימות לפרוטר טענות כנגד הרישום אזי מקומן להתברר בבית המשפט המחוזי.

01. דוד המים החמים הותקן ע"י הקבלן שבנה את הבית מטעם בעלת הקרקע ולא ע"י מילר. התקנתו במיקום נושא ההליך נעשתה בעטייה של טעות בתכנון או בביצוע שמנעו את האפשרות להתקין את הדוד בתוך הדירה בהיעדר תשתית וצנרת מתאימים בדירת מילר.

11. הדוד הותקן טרם קבלת טופס 4 ומיקומו אושר ע"י הרשויות בבדיקות לטופס 4. הדוד מותקן בחלל אנכי הסמוך לחלון חדר האמבטיה של מילר, ברום המסדרון המוביל למחסנים באופן שאינו נראה לעין, אינו מפריע לשימוש סביר כלשהו ברכוש המשותף ואינו נוזל.

21. חלף מזגן מיני מרכזי הותקנו מזגנים מפוצלים בדירת מילר בשל העובדה שההכנות למיזוג שהתקינה מוכרת הדירה נמצאו בלתי תקינות. המזגנים פונים לכיוון הוואדי, אינם נראים משום חזית ואינם מרעישים. גם בעלי דירות אחרים בבית התקינו מזגנים והתובעים לא מצאו לנכון לתבוע אותם על כך.

טענות התביעה שכנגד-

31. יש להורות לפרוטר לסלק את ה דלת שהתקינו במסדרון המצוי בקדמת ה מחסן של מילר על מנת לאפשר למילר גישה למחסן שבבעלותם, הוא המחסן המסומן בספרה 3 בתשריט רישום הבית המשותף (להלן: "המחסן"). לחילופין, יש להורות לפרוטר למסור מפתח דלת זו למילר.

41. היות וממסמכי רישום הבית המשותף עולה כי המחסן בבעלות מילר, אזי יש להורות לפרוטר לסלק ידם ממחסן זה בו תפסו חזקה.

51. מאחר ופרוטר תפסו חזקה במחסן הרשום בבעלות מילר יש לחייב את פרוטר בדמי שימוש ראויים בעבור המחסן מיום 1.6.08, מועד רישום המחסן בבעלות

מילר, ועד ליום 31.5.13 מועד עריכת חוות הדעת השמאי שהגישו מילר במצורף לתביעתם.

טענות ההגנה שכנגד-

67. מתצהיר שהגיש מילר בהליך שהתקיים בבית המשפט השלום בחיפה עולה כי מילר מודע לכך שהמחסן אינו שייך לו ו כפי העולה מהתצהיר אין לו בו כל עניין. מאחר ו הליך תלוי ועומד בפני בית משפט אחר בנוגע לאותו המחסן מנועה המפקחת מלדון ולפסוק בו.

71. פרוטר ריצפו את המחסן על חשבונם והת קינו על חשבונם את הדלת בכניסה למסדרון בו מצוי המחסן, וזאת בהתאם לדרישות הכיבוי וכתנאי לקבלת טופס 4. הם מחזיקים במחסן חזקה ייחודית מיום שנבנה הבית.

ההליכים בתיק-

81. בדיון שהתקיים לפניי ביום 10.12.12 הסכימו התובעים למחוק מהתביעה את הדרישה לצו עשה שיורה למילר להרוס את המחסן שבנו תחת גרם המדרגות. עוד הוסכם באותו הדיון לגבי המתווה לתיקון צינור הביוב העובר בקיר חדר האמבטיה של מילר ולגבי המתווה להתקנת צינור ניקוז ב חצר מילר. הסכמות אלו קיבלו תוקף מחייב ומשכך אינני נדרשת להן בפסק דיני זה.

91. ביום 20.6.13 וביום 3.7.13 התקיימו דיוני הוכחות ב הם העידו מטעם התביעה וההגנה שכנגד מר פרוטר ומר רימוני, שני בעלי דירות בבית, ומטעם ההגנה והתביעה שכנגד העיד מר מילר. הצדדים סיכמו טענותיהם בע "פ. חלקים מהעדויות ייסקרו בפרק הדיון.

02. ביום 2.7.13 התקיים ביקור במקום בנוכחות הצדדים וב "כ על מנת לה תרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען. להלן הנתונים הרלוונטיים להליך:

(א) מדובר בבית בן 4 דירות שחזיתו פונה לרח' ראול וולנברג ועורפו פונה לכיוון הוואדי.

(ב) מעל מפלס הרחוב מצויה דירת מ' ש' רימוני. אל יתר הדירות מוביל חדר המדרגות של הבית היורד ממפלס הרחוב מטה.

(ג) דירת מילר מצויה מפלס אחד מתחת לקומת הרחוב. בחדר המדרגות הסמוך לה קיים גרם מדרגות ותחתיו חלל אשר נסגר ע"י דלת המשמש כשטח אחסנה של מילר.

(ד) מפלס אחד מתחת לדירת מילר מצויים דירת פרוטר וכן שני מחסנים : האחד שייך לרימוני והאחר לפרוטר. אל מחסנים אלו מוביל מסדרון אשר משמש רק את שני מחסנים אלו. ברום החלל המצוי מעל אותו המסדרון הותקן דוד המים החמים של מילר באופן שהוא נמצא בסמוך לחלון חדר האמבטיה של הם. על רצפת המסדרון תחתיו ניכרו סימני קרצוף בחומר חזק שיצרו הפרשי גוון בין הריצוף המקורי במסדרון לבין הריצוף המקורצף. נטען בביקור כי טרם הקרצוף "סבל" האריח מכתמי חלודה שנגרמו בעטיו של טפטוף מים מהדוד.

(ה) בדירות רימוני ופרוטר הותקן דוד המים החמים בתוך הדירה, בכל דירה הותקן הדוד במיקום שונה.

(ו) מפלס אחד מתחת לדירת פרוטר מצויים שני מחסנים נוספים. האחד רשום בבעלות מילר והאחר רשום בבעלות אלאוף. בקדמת מחסנים אלו הותקנה דלת אשר המפתח לה מצוי בידי פרוטר. שטח המחסנים והמסדרון שנתחם ע"י אותה הדלת חשוכים, נעדר תאורה טבעית או מלאכותית. על מנת לראות את פנים חללים אלו נעזרתי בפנס.

(ז) הצדדים להליך הסכימו כי מש' אלאוף (בעלי דירה נוסף בבית שאינם צד להליך) תפסו חזקה בשטח חלל גדול במיוחד הסמוך לדירתם ומחזיקים בו חזקה ייחודית. היות ונושא זה אינו מהווה חלק מחלוקת שלפניי לא מצאתי לנחוץ לבקר באותו המפלס ובאותו החלל.

(ח) על הקירות החיצוניים של הבית המשותף התקינו מילר וכן בעלי דירות נוספים מזגנים וצנרת שירות למזגנים. מזגנים אלו אינם נראים מכיוון הרחוב והותקנו על גבי הקירות החיצוניים הפונים לכיוון הוואדי.

דיון והכרעה-

12. אקדים ואציין כי מצאתי לדחות את התביעה שהוגשה כנגד מילר ו לקבל את מרבית התביעה שכנגד שהוגשה כנגד פרוטר. הכול כפי שיפורט להלן.

דוד המים החמים-

22. אכן בביקור במקום מצאתי כי דוודי המים המשרתים את דירות רימוני ופרוטר הותקנו בתוך דירותיהם. נטען ע"י פרוטר, ולא הוכחש ע"י מילר, שגם בדירה הרביעית היא דירת אלאוף מותקן דוד המים בתוך הדירה. אין חולק, אם כן, כי הדוד היחיד שהותקן ברכוש המשותף הוא דוד המים המשמש את מילר.

32. המחוקק הקנה לאסיפה הכללית בבית סמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף (ראה: ע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח' פ"ד מ(1) 724). בהעדר החלטה מסוימת שכזו של האסיפה הכללית רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף בהתקיים שני תנאים מצטברים:

התנאי הראשון הוא שהשימוש המבוצע הינו שימוש רגיל וסביר, קרי, שימוש אשר תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות. תנאי המקום משמעם המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחר, משרדים וכד'). תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שהמציאות מכתיבה (ראה: פרופ' י' ויסמן דיני קניין – בעלות ושיתוף (תשנ"ז) בעמ' 488-490).

התנאי השני הוא השימוש אותו מבצע בעל דירה ברכוש המשותף אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה פ"ד כ"ח (1) 645; ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג פ"ד כח (2) 817; ע"א 458/82 וילנר נ' גולני פ"ד מב (1) 49 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה (4) 277).

42. נשאלת אם כן השאלה האם מדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף כזה שרשאי מילר לעשותו אף ללא צורך בהסכמות מי מבעלי הדירות בבית או שבהיעדר הסכמות ב עלי הדירות יש לקבל את תביעת התובעים ולהורות על סילוקו מהרכוש המשותף והעתקו לתוך דירתם.

52. פרוטר העיד כי הדוד הותקן במסדרון מעל ראשי עוברים ושבים וכי הותקן בצורה רשלנית המסכנת עוברים ושבים. ראו עדותו בעמ' 5 לפרוטוקול שורות 18-21 ובעמ' 8 שורות 10-13. עוד העיד ה עד כי דוד זה, בדומה לכל יתר הדו ודים בבית, הותקן באמצעות חב' כרומגן וההתקנה הוזמנה על ידי הקבלן שבנה את הבית. ראו עדותו בעמ' 8 שורות 1-6. גם מעדות מילר עלה כי הדוד הותקן ע"י חב' כרומגן בשם הקבלן וכי ההתקנה בוצעה טרם שנכנס לגור בדירתו. ראו עדותו בעמ' 16 שורות 24-27. לגבי הסיבה להתקנת הדוד במיקום האמור העיד מילר בעמ' 17 שורות 9-12 כדלהלן:

"ת. אני לא מבין באינס', אבל מה שהבנו מהקבלן שלא הותקנה תשתית של מים חמים וצנרת שתעביר את המים אל מרפסת הכביסה. ולכן המקום היחיד שניתן היה להתקין זה המקום שהוא נמצא בו היום. בפיר האנכי שמשתרע על פני 9 מ' סמוך לאמבטיה שלנו."

62. מעדותו של מילר, שלא הוכחשה, עלה כי דירתם נעדרת תשתית המאפשרת התקנת הדוד בתוך דירתם. כן לא נסתרה טענתם כי אותו הקבלן שהתקין לכל בעלי הדירות בבית את הדודים הוא אשר התקין למילר את הדוד במיקום נושא ההליך.

72. טענה זו בדבר 'צורך' להתקינו דווקא ברכוש המשותף אינה יכולה לבדה להקים למילר זכות כי דוד זה יותקן ברכוש המשותף, ועל כן מצאתי לנכון לקיים ביקור במקום כדי להתרשם גם מסבירות השימוש שנעשה ברכוש המשותף למטרה זו. לאחר שקיימתי את הביקור במקום שוכנעתי כי התקנת הדוד במ יקום נושא ההליך עולה כדי שימוש סביר שעושה בעל דירה ברכוש המשותף. ואפרט- מצאתי בביקור כי הדוד מותקן במקום נסתר שאינו נראה לעין. עוד מצאתי כי במיקום בו הותקן הדוד לא ניתן לעשות שימוש אחר כלשהו, ואין בהתקנתו שם כדי לסכל אפשרות לשימוש סביר אחר באותו חלל. ממצאי הביקור במקום היו חד משמעיים מדובר בשימוש סביר שאינו מונע מבעלי הדירות בבית כל שימוש סביר אפשרי אחר באותו השטח, וגם אינו פוגע בחזות הבית האחידה והתקינה. חיזוק לעמדתי זו מצאתי גם בעובדה שהדוד הותקן במקום כבר בשנת 2004, קרי, לפני כתשע שנים ולא נשמעה טרזניה ש ל מי מבעלי הדירות בבית בעניין טרם הגשת התביעה.

82. זאת ועוד, העובדה שמהתמונות שהוצגו לפניי עלה כי הדוד טפסף וגרם לכתמי חלודה גם היא אין בה כדי לשנות מהחלטתי זו. היעלה על הדעת כי ברגע שדוד שמש המונח על גג בית משותף מטפסף בשל תקלה כלשהי תימנע הנחת דוודי ם על גבי הגג המשותף? ברי כי מילר חייבים לדאוג כי בכל רגע נתון יהא הדוד תקין, וכי לא יהא בו כדי לגרום לנזק לרכוש המשותף, וככל שנוזק ייגרם יהיו הם אחראים לתקן על חשבונם ובמידי את הנזקים שייגרמו.

92. לא מצאתי גם לקבל את הטענה כי אין לאפשר הותרתו של דוד המים על מכונו מהטעם שהוא עשוי לגרום להצפת המחסנים במקרה של תקלה. האפשרות כי דוד ייפגם ויגרום להצפה חמורה קיימת גם מקום בו מותקן דוד המים במיקום אחר. העובדה שהדוד הותקן ברכוש המשותף אינה פוטר את בעליו מהאחריות המוטלת על כל בעל דוד מים לדאוג כי דוד המים יהיה בכל רגע נתון במצב תקין.

03. לאור האמור אני דוחה את התביעה למתן צו עשה שיורה על העתקת דוד המים.

המזגנים-

13. הוראת סעיף 2(א) לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובעת בזו הלשון:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכ ן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה". (הדגשה שלי י.ל.)

בהתאם להלכה שנקבעה בע"א 163/63 לווינהיים ואח' נגד שוורצמן ואח' פ"ד י"ז, (3) 1722 ושלא שונתה עד היום, אין בעל דירה רשאי לעשות שינויים או תיקונים בדירתו הפוגעים ברכוש המשותף, אלא אם קיבל **תחילה** הסכמת **האסיפה הכללית** של בעלי הדירות.

23. אכן בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בין ברכוש המשותף ובין בדירה אחרת, כהוראת סעיף 2 שצוטט לעיל אלא אם קיבל תחילה את הסכמת בעל הדירה האחרת או הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות, לפי הענין.

33. יחד עם זאת נקבע בפסיקה שהתקנת מזגנים הינה שימוש סביר ברכוש המשותף בתנאי מזג האוויר של הארץ. ראו ע"א 991/97 נציגות הבית המשותף נ' לילי אבן [לא פורסם] וכן ראו ת"א 487/11 רחל רוזיק נ' שירה רביד [לא פורסם] שם נקבע:

" מגמת הפסיקה כיום נוטה להקל בנושא התקנת מזגנים בהתחשב בתנאי האקלים בקיץ הישראלי ולהתייחס אליה כשימוש רגיל וסביר. המבחן בין היתר הוא שימוש בהתאם לנסיבות המקום תוך התחשבות באלטרנטיבות אחרות הנתונות למבקש התקנת המזגן, כל אימת שההתנגדות להצבת המזגן אינה נובעת מהפרעה ממשית לשכנים ולציבור בין אם בשל ראש או מפגע בטיחותי ובין אם בשל פגיעה אסתטית בולטת או פגיעה ממשית אחרת, ניתן לראותה כבלתי סבירה, ואת השימוש במזגן יש לראות כשימוש רגיל".

43. שומה אפוא על מי שמתקין מזגן, שיתקינו באופן שיהווה שימוש סביר ברכוש המשותף, והמעטפת החיצונית של הבית הינה במובהק רכוש משותף, ובעיקר – שיתקינו בתום לב ובהגיונות. הפסיקה מייחסת חשיבות עליונה לחובת מימוש הזכויות של בעלי דירות בבית משותף בתום לב, בהגיונות, ביושר, ומתוך התחשבות בצרכי הזולת. ראה רע"א 8186/07 כרמל נ' ינקוביצקי, (לא פורסם, 1.1.2008).

53. נשאלת אם כן השאלה אם התקנת מנועי המזגנים על ידי מילר במקום ובאופן שהותקנו הינה בתום לב ותוך התחשבות בצרכי הזולת?

63. לשאלת השימוש הסביר בקירות הבית לשם התקנת מזגנים אציין כי כשפרוטר נשאל מדוע תבע רק את מילר ולא את יתר בעלי הדירות בבית להם הותקנו מזגנים על הקירות החיצוניים השיב בעמ' 8 שורות 17-35 כדלהלן:

"למה לא הגשת בתביעה נגד רימוני שיסיר את המזגן שלו?
ת. המזגן הזה נמצא בקיר המזרחי של הבניין שלא מפריע לאף דייר. הוא מוסתר. יש הבדל בין הקירות החיצוניים שבהם צינורות של משמ' מילר לבין הקיר הזה שהוא מוסתר בין שני בניינים ואף אחד לא רואה אותו. יש לנו מבנה אשפה גדול שמסתיר את כל הקיר הזה ואין מה להשוות בין

ההפרעות של המזגן הזה לבין המזגנים של מש' מילר. המזגן הזה לא מרעיש. אני לא שומע אותו. מעולם הם לא אמרו לנו שהמזגן מפריע להם. ש. המזגן הזה נמצא במקום המיועד לכך לפי טענתך מתוך הגרמושקה למנועים של מזגנים שהקבלן הכין?

ת. לא. הוא לא נמצא.

ש. אני מציג לך תמונה שצולמה בבנין, האם אתה מזהה את המזגנים שלך על הקיר החיצוני?

ת. לא. זה לא קיר זה גינה. לשאלתך – א ני מזהה את המזגנים שלי – אבל זה לא מזגנים, יש לי מזגן מפוצל המחולק לשניים – מדחס מרעיש שנמצא אצלי בתוך הדירה בהנמכת התקרה והוא מקור הרעש גדול ומאוויר שנמצא בחוץ ולא עושה רעש בכלל. מה שרואים בתמונה זה המאוורר של שני המיני מזגנים שמורכבים אצלי והם נמצאים שתי קומות מתחת מש' מילר ולא מרעישים.

ש. האם הצינוורות שנראים בתמונה שיוצאים מהמזגן הם צינוורות שלך?

ת. כן. אבל הם נמצאים בגינה שלי ואף אחד לא רואה אותם. מוגש ומסומן 1/1."

73. עינינו הרואות שגם פרוטר מסכים שכלל שמזגן מותקן על קירות הבית באופן שאינו בולט לעין ואינו מהווה מפגע רעש אין כל מניעה כי יותקן על קיר חיצוני.

83. לאחר שקיימתי ביקור במקום נחה דעתי כי התקנת המזגנים עולה כדי שימוש סביר ברכוש המשותף.

93. אמנם נטען כי הקבלן הכין תשתית להתקנת מזגנים מיני מרכזיים לדירות וכי הנתבעים צריכים היו להתחבר אליהם, אך בנסיבות תיק זה לא מצאתי לקבל טענה זו משום עקרון תום הלב שאוזכר לעיל. הביקור במקום תאם את עדויות הצדדים מהן עלה כי לפחות ל- 3 מ-4 בעלי דירות בבית ה תקינו מזגנים על גבי הקירות החיצוניים באופן דומה למזגנים של מילר והנציגות לא מצאה לנכון לתבוע אף לא אחד מהם.

04. לא מצאתי את המזגנים שהתקינו מילר וגם לא את יתר המזגנים התקינו בעלי דירות אחרים בבית פוגעים בחזות הבית. אמנם מהמזגנים גם יוצאת צנרת העוברת באופן חיצוני על פני קירות הבית אך צנרת זו, כמו גם המזגנים עצמם אינם בולטים לעין. המזגנים והצנרות אינם נראים מהרחוב או מחזיתות אחרות וכולם פונים לכיוון הוואדי באופן שאינם פוגעים בחזות הבית.

74. באשר לטענה כי המזגנים של מילר מהווים מפגע רעש. טענה זו נטענה בעלמא ולא הוכחה. לא יכולתי להתרשם מעוצמת הרעש של המזגנים היות והללו לא הופעלו בעת הביקור במקום וממילא גם לא היו בידי אמצעים למדידת רעש, וגם לא הובאה חוות דעת מומחה לרעש שתתמוך בנטען ולפיכך לא מצאתי כי טענה זו הוכחה.

24. לאור האמור אני דוחה את התביעה למתן צו עשה שיורה על סילוק המזגנים והצנרת.

התביעה שכנגד-

34. בכתב התביעה שכנגד נטען להסגת גבול של פרוטר במחסן שבבעלות מילר והתובעים שכנגד עתרו לסילוק ידם של פרוטר מאותו המחסן. היות ונדרשת אני לדון בגררא לשאלת הבעלות במחסן אקדים ואבחן האם קיימת לי הסמכות לעשות כן.

הסמכות לדון בזכויות הקנייניות-

44. ס' 74 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") קובע:

"למפקח הדן בסכסוך יהיו כל הסמכויות שיש לשופט בית-משפט שלום הדן בתביעה אזרחית"

54. בר"ע 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2 נ' דן ירדני, פ"ד לח (4), 487, עמ' 496-497 נאמר:

"השאלה השנייה: האם הוסמך המפקח לדון כעניין שבגררא, בגדר תובענת סילוק היד שהוגשה לפניו, בזכויותיהם ה"קנייניות" של המשיבים?

לדידי אין הדבר מוטל בספק; כך הוחלט כבר לעניין הפקיד המוסמך לפי חוק בתים משותפים [נוסח משולב], קודמו של המפקח, שהמחוקק לא הקנה לו, כמו למפקח, סמכויות של בית-משפט שלום: ע"א 191/66, והוא - כדי למנוע תוצאה, שעל-פיה "יבצר מהפקיד המוסמך לעשות את המלאכה שהחוק הטיל עליו" (ראה דעת הרוב, מפי השופט זוסמן ז"ל, כתוארו אז, שם, בעמ' 510); קל וחומר הוא במפקח, שהוא "בית-דין" למהדרין: ע"א 44/72, שסמכויותיו הן כסמכויות בית-משפט שלום; כפי שמוסמך המפקח ליתן צו הריסה, כמו בית משפט שלום בגדר סעיף 75 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] (מקודם סעיף 34 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957): ע"א 768/80, כך רשאי הינהו, לצורך העניין שלפניו, לדון בגררא בשאלה, שהכרעתה דרושה לבירור העניין, אף אם העניין שבשאלה הוא בסמכותו הייחודית של בית המשפט המחוזי (סעיף 76 לנוסח המשולב, מקודם סעיף 35 לחוק משנת תשי"ז); וכבר נפסק, שלא ברשות שבשיקול-דעת עסקינן אלא בסמכות חובה: ע"א 89/63. והשווה: ע"א 510/82."

64. סעיף 72 לחוק המקרקעין הקובע את סמכויות המפקח על רישום מקרקעין אינו כולל בחובו סכסוכים שעילתם בעלות. השאלה האם נפלה שגגה בעת רישום הבעלות במחסן ע"ש מילר היא שאלה שבבעלות וככזו נתונה לסמכותו הייחודית

של בית המשפט המחוזי . ואולם, ככל ששאלת תקינות הרישום עולה אגב התביעה לסילוק יד מוסמכת אני לפסוק בה בגררא. וראה גם ע"א 7516/06 תמיר שי נ' שלוה הסל ואח' פורסם ביום 11.10.10 שם נקבע כי לגבי הקביעות והממצאים שקבעה המפקחת בנוגע לחדר הביטחון כי:

" החלטת המפקחת ניתנה במישור זכויות החזקה והשימוש בלבד ולא התיימרה לדון כלל בזכויות הקנייניות (בעמוד 8 להחלטה)"

ובהמשך פסה"ד:

"אף לו היתה מוכרעת שאלת הבעלות בגררא על ידי המפקחת (סברה שאינני מקבלת, כאמור), לא היה בהכרעה זו בכדי לכבול את ידיו של בית המשפט הנכבד קמא (בית המשפט המחוזי- הוספה שלי י.ל.)- אשר לו מסורה הסמכות הייחודית לדון בנושא- להידרש בשנית לשאלה זו ולפסוק בה כטוב בעיניו".

74. לאור האמור אני מוצאת כי קיימת לי הסמכות לדון בתובענה זו.

84. לא מצאתי כי יש לעכב ההליכים בהליך לפניי בנוגע למחסן היות וקיים הליך תלוי ועומד בבית המשפט השלום לגבי אותו המחסן. פרוטר אמנם הפנו אותי להליך שמתקיים בבית משפט השלום בת"א 10834-06 הופמן ואח' נ' פרוטר ואח' בטענה כי שם נידונה בין היתר סוגיית המחסן ומשכך אין להידרש אליה כאן, ברם, טענה זו לא הוכחה. פרוטר לא צירפו את כתב התביעה הרלבנטי או כל מסמך אחר שיוכיח כי התבקש סעד כלשהו בהתייחס לאותו המחסן.

המחסן-

94. מסמכי רישום הבית המשותף מלמדים כי הבעלות במחסן נרשמה כבר בשנת 2008 על שם מילר. המחסן סומן בספרה 3 בתשריט רישום הבית המשותף ונרשם בתיאור הדירה כחלק מדירתם.

05. פרוטר אמנם טוענים כי רישום הבעלות במחסן על שם מילר בטעות יסודו, אך בה בעת לא עשו דבר וחצי דבר כדי לתקן את הרישום האמור. אין חולק כי לא הוגשה תביעה לתיקון הרישום לבית המשפט המוסמך.

15. מילר העיד בחקירתו הנגדית לגבי המחסן נושא ההליך כדלהלן:

"ת. כבר עניתי על זה. שלא הובטח לי מחסן זה בחוזה המכר. בעל פה עו"ד דה קאלו אמר לי שאקבל מחסן נוסף.
ש. ההבטחה שאתה טוען שקיבלת מעו"ד דה קאלו אינה ספציפית למחסן מסוים, ואין הכוונה דווקא למחסן הספציפי הזה שמחזיק בו מר פרוטר.
ת. בע"פ הוא אמר שנקבל מחסנים. לא דיברו על המחסן הספציפי הזה.

ש. כלומר אין לך לא הבטחה חוזית למחסן הזה ואין לך הבטחה בעל פה למחסן הספציפי הזה.

ת. לא, אבל יש לי טאבו על המחסן הזה. לא יתכן שמקום שיש לי טאבו על המחסן הזה תימנע ממני הנגישות אליו. " (הדגשות שלי י.ל.)

ראו עדותו בעמ' 24 שורות 6-14.

25. מילר הודה בעדותו כי לא קיבל הבטחה חוזית ביחס למחסן נושא הליך זה וכי נרשם על שמו בפועל מחסן שונה מזה שהובטח לו בחוזה המכר. ראו עדותו בעמ' 23 שורות 36-38 שם מעיד מילר כדלהלן:

" ש. כעולה מסעיף 12 ו- 14 לתצהירך, הובטח לך דבר אחר ממה שנרשם בפועל. איך אתה מסביר את זה?
ת. בחוזה המכר הובטח לי המחסן במפלס הדירה שלנו.
ש. ולא 3+?
ת. נכון, הוא לא הובטח לנו.
ש. האם נרשם על שמך בטאבו משהו אחר ממה שהובטח לך?
ת. נכון, מחסן 3. גילינו את זה באוג' 2008. רק אז נרשמה הדירה בטאבו ואז מצאנו שהמחסן הזה רשום על שמנו. " (הדגשות שלי י.ל.)

35. מנגד לא מצאתי כי פרוטר הוכיח את זכותו לבעלות באותו המחסן. פרוטר העיד כי בתשריטים שהוגשו במסגרת הבקשה להיתר בנייה הופיע המחסן נושא ההליך כחלל לא מבונה. ראו עדותו בעמ' 6 לפרוטוקול שורות 11-16. לדבריו בהמשך שונה חלל זה והופיע בתכניות מאוחרות יותר שהוגשו לוועדה המקומית כשני מחסנים. ראו עדותו בעמ' 7 שורות 29-31. פרוטר העיד כי מחסן זה הובטח לו על ידי הקבלן וכי לאור זאת ריצפו הם על חשבונם את המחסן והתקינו דלת אש על חשבונם במסדרון המוביל למחסן זה. ראו עדותו בעמ' 7 שורות 38-40. עדות זו של פרוטר לא נתמכה בראיה כלשהי שתוכיח טענתו זו. פרוטר לא הצג את הסכם המכר שחתם עם הקבלן להוכיח כי מחסן זה הובטח לו, לא הציג מסמך כלשהו אחר מאת הקבלן או מאת מאן דהוא אחר שיוכיח כי מחסן זה הובטח לו וגם לא הזמין את הקבלן לעדות.

45. כבר נפסק כי הימנעותו של צד מגילוי ראייה יכול שתביא את בית המשפט לידי מסקנה כי אילו הוצגה א ותה הראיה, זו הייתה פועלת לרעתו [ראו למשל: ע"א 548/78 שרון נ' לוי, פ"ד לה (1) 736, 760 (1980), וכן ראו: קדמי 1408-1391 והאסמכתאות שם], וזו דעתי באשר לסיבת הימנעות פרוטר מלהציג את חוז המכר שנחתם עימו.

55. השאלה על מי מהצדדים מוטלת חובה להעיד עד רלבנטי, וכפועל יוצא המסקנה כי יש לזקוף לחובת צד זה או אחר את אי העדתו של צד זה, נקבעת בהתאם לנטל הבאת הראיות [ראו: ע"א 78/04 המגן ח ברה לביטוח בע "מנ" שלום גרשון הובלות בע "מ, פסקה 53 לפסק הדין ([פורסם בנבו], 5.10.2006)]. במקרה שלפנינו, היות והבעלות במחסן רשומה על שם מילר ופרוטר מבקשים לטעון כנגד

הבעלות הרשומה אזי נטל הבאת הראיות היה מוטל על על פרוטר שכן הרישום מהווה ראיה חותכת לתוכן (סעי' 125 לחוק המקרקעין). וראו הדברים שנקבעו ברע"א 296/11 מוחמד נג'אר נ' שאוקי חמדאן עליאן (לא פורסם) שם נקבע כי קיים היפוך בנטל הבאת הראיות מקום בו טוען אדם כנגד בעלות רשומה . וכך נקבע באותו פסק דין :

"כאשר אדם ידוע כבעליה של חלקת קרקע , וחברו טוען שהוא קנה או תה ממנו, החבר הוא הטוען לשינוי המצב הקיים, ועליו לשאת בנטל הראיה."

65. וזאת יש לזכור , הבעלות במחסן נושא ההליך רשומה ע "ש מילר . אמנם עדות מילר העלתה תהיות באשר לנכונות הרישום הנוגע למחסן נושא ההליך , ואולם, על פרוטר מוטל נטל הראיה להוכיח כי להם הובטחה הבעלות באותו המחסן וכי זו אף עוגנה בחוזה המכר . פרוטר לא עמדו בנטל ה ראיה ולא הוכיחו שהבעלות צריכה להיות רשומה על שמם וכי הם מחזיקים במחסן כדין.

75. גם טענתם כי המחסן מחובר לחשמל הביתי שלהם לא הוכחה, לא במסמכים ולא בביקור במקום. כפי שתואר לעיל , בביקורי במקום מצאתי כי לא ני תן להפעיל תאורה באותו מחסן כלל. הוא הדין לגבי הטענה שהנתבעים ריצפו על חשבונם את המחסן והתקינו על חשבונם את דלת האש. טענות אלו לא הוכחו.

85. מכלל הראיות שבאו לפניי עלה כי פרוטר לא הוכיחו זכות כלשהי לבעלות במחסן, ודי בכך כדי להורות על סילוק ידם מהמחסן. מנגד מילר אמנם אישרו כי המחסן שנרשם על שמם אינו תואם את המחסן שהבטיח להם הקבלן שבנה את הבית , אך בפועל המחסן היה ועודנו רשום על שמם , ודי בכך כדי להורות לפרוטר להעביר את החזקה במחסן , וליתן את מפתח הדלת המובילה אל אותו המחסן למילר.

דמי שימוש ראויים-

95. סמכותו השיפוטית של המפקח על רישום המקרקעין מעוגנת בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן : "חוק המקרקעין") הקובע כדלהלן :

"(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח - 2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו - 27ג לחוק הבזק , תשמ"ב 1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף , רשאי התובע להביאו , לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו - (ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך , ואם הייתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות..."

06. בע"א (ת"א) 1730/90, צ.ה.ר. חברה לפתוח ובנין בע"מ ואח' נ' יום טוב בע"מ (לא פורסם) נקבע ע"י כב' השופטת חיות כדלקמן:

"מהוראות סעיף 72 (א) לחוק המקרקעין עולה כי קיים קשר ומתאם בין סמכותו של המפקח ובין עילות התביעה המנויות באותו הסעיף. במילים אחרות, המפקח מוסמך לדון אך ורק בעילות לפי התקנון או לפי הסעיפים המנויים בסעיף 72 (א) הנ"ל. סעיף 72 (ג) מרחיב אמנם את מעגל המתדיינים בפני המפקח, כאמור, אך הוא מתנה ומתלה את סמכותו של המפקח לדון בסכסוך בכך שמדובר בסכסוך כאמור בס"ק (א), כלומר בעילת תביעה הצומחת מן התקנון או מן הסעיפים המנויים בסעיף 72(א) הנ"ל".

16. ההלכה שנקבעה בפסק דין זה אושרה בפסק דין של הרכב בית המשפט המחוזי, אב"ד כב' השופט גרוס בע"א (ת"א) 1480/02, גרש נ' נציגות הבית המשותף (לא פורסם).

26. למפקח על רישום המקרקעין סמכות שיפוטית, אפוא, לדון בסכסוכים בדבר זכויות וחובות בין בעלי דירות בבית משותף על פי התקנון הרשום של הבית או על פי סעיפים אחרים של חוק המקרקעין המנויים בסעיף 72 הנ"ל.

36. התובעים לא הצביעו על המקור הנורמטיבי לחיובו של הנתבע ב דמי שימוש ראויים. אני סבורה כי דמי שימוש ראויים נגזרים מעילת "עשיית עושר ולא במשפט" ומהווים תרופה מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט התשל"א – 1979. ככאלו, הם אינם מצויים בגדר סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין.

46. זאת ועוד, מקור נורמטיבי אחר לחיוב בדמי שימוש יכול לקום מכוח סעיף 33 לחוק המקרקעין ה קובע כי שותף במקרקעין שהשתמש במקרקעין משותפים חייב ליתר השותפים שכר ראוי בעד השימוש, יחד עם זאת, סעיף 56 לחוק המקרקעין החריג בצורה מפורשת וברורה את תחולת הוראות פרק ה' (הוא הפרק בחוק המקרקעין בו מצוי סעיף 33) על בתים משותפים.

56. לאור זאת לא מצאתי כי קיימת לי הסמכות לפסוק דמי שימוש ראויים.

66. למעלה מהדרוש אציין כי אפילו הייתי מוצאת כי קיימת לי הסמכות לפסוק דמי שימוש ראויים ספק אם הייתי מזכה את מילר בדמי שימוש ראויים. הטעם לכך נעוץ בעובדה שפרוטר העלו ספק אמיתי באשר לנכונותו של הרישום לגבי המחסן נושא ההליך ועדותו של מילר חיזקה ספק זה.

76. מעדויות הצדדים עלה כי קיים ספק ממ שי באשר לזכותם של מילר להיות רשומים כבעלים של המחסן, מנגד פרוטר לא הוכיחו זכותם הם לבעלות על אותו המחסן. לאור זאת, אין להוציא מכלל אפשרות שככל ש הצדדים יקיימו הליך לפניי בית המשפט המוסמך לפסוק בשאלת הבעלות במחסן זה, ימצא בסופו של

הליך כי לא הוכחה בעלותם של אף לא אחד מהצדדים להליך זה על המחסן, וכפועל יוצא אפשר שיימצא כי המחסן צריך בכלל להירשם כרכוש משותף.

86. לאור זאת ומשום שדמי שימוש ראויים מקורם, כאמור, בדיני עשיית עושר ולא במשפט סבורה אני כי במצב דברים זה אין זה נכון לזכות את מילר בדמי שימוש ראויים בעבור התקן פה הרלוונטית להליך, מקום בו הודו בעדותם כי "זכו" למחסן שכלל לא הובטח להם.

96. חיזוק לעמדתי זו מצאתי גם בעובדה ש אלמלא הוגשה התביעה כנגד מילר סביר כי התביעה שכנגד, במסגרתה נתבעו דמי השימוש הראויים, לא הייתה כלל באה לעולם. ראיה לכך היא העובדה ש למרות שכבר בשנת 2008 גילו מילר כי הבעלות במחסן נרשמה על שמם לא טרחו להגיש תביעה כנגד פרוטר עד אשר אלו הגישו תביעה כנגדם ולא הביעו מחאה כלשהי. בנסיבות אלו דומה כי השימוש אשר נעשה על ידי פרוטר הוא בבחינת רשות חנם.

סוף דבר-

07. אני דוחה את התביעה שהגישו התובעים כנגד מילר.

17. אני מקבלת את התביעה שהגישו מילר כנגד פרוטר בחלקה, ומורה לפרוטר להעביר למילר, בתוך 30 יום מהיום, את המפתח לדלת המותקנת בקומה בה מצוי המחסן המסומן בתשריט רשום הבית המשותף בספרה 3 וכן את החזקה באותו המחסן.

27. לא מצאתי לקבל את התביעה לדמי שימוש ראויים.

37. אני מורה לפרוטר לשלם למילר הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 4,500 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (19.6.12) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ט' באב התשע"ג (23.7.13).

העתקים יישלחו לצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין